

刑法
No14

H28-17 (配点: 3)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、甲に()内の罪名の間接正犯が成立しないものを2個選びなさい。

1. 甲は、是非弁別能力を有する12歳の長男乙に対し、強盗の犯行方法を教示し、その際に使う凶器を提供して強盗を実行するよう指示したが、その指示は乙の意思を抑圧するものではなく、乙は、自らの意思により強盗の犯行を決意し、甲から提供された凶器を使って、状況によって臨機応変に対処して強盗を実行した。(強盗罪)
2. 医師ではない甲は、妊婦乙からの依頼を受けて乙への堕胎手術を開始したが、その最中に乙の生命が危険な状態に陥ったため、医師丙に依頼し、胎児を乙の母体外に排出させた。(同意堕胎罪)
3. 公務員ではない甲は、公証人乙に対して虚偽の申立てをし、事情を知らない乙をして、公文書である公正証書の原本に虚偽の記載をさせた。(虚偽公文書作成罪)
4. 甲は、事情を知らない新聞社の従業員乙に依頼して、同社の新聞紙上に、丙に無断で丙名義の事実証明に関する広告文を掲載させた。(私文書偽造罪)
5. 甲は、乙所有の建材を自己の所有物であると偽って、事情を知らない丙に売却し、丙をして、乙の建材置場から当該建材を搬出させた。(窃盗罪)

No14	間接正犯の成否	正答率
H28-17	正解 1、3 (順不同)	73%

間接正犯とは、他人を道具のように利用して犯罪を実現する場合をいう。現行の刑法典には間接正犯を認める条文上の規定はないが、他人をあたかも道具のように利用して犯罪を実現することは不可能ではなく、規範的には自ら実行行為をしたものと評価することができるから、解釈上間接正犯を認めても罪刑法定主義に反しない（通説）。間接正犯が認められるためには、他人の行為を自己の犯罪実現のための道具として利用したといいうことが必要である（最判平9.10.30）。

1 成立しない

最決平13.10.25。本記述では、是非弁別能力を有する刑事未成年者である被利用者が自らの意思により強盗の犯行を決意し、状況に応じて臨機応変に対処して強盗を実行した場合に、利用者が強盗罪（236条）の間接正犯となるかが問題となる。判例は、母親Aが生活費欲しさから強盗を計画し、12歳10か月の長男Bに指示命令して強盗を実行させたという事案において、「本件当時B〔注：本記述の乙に当たる〕には是非弁別の能力があり、被告人〔注：本記述の甲に当たる〕の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のものでなく、Bは自らの意思により本件強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して本件強盗を完遂したことなどが明らかである。これらの事情に照らすと、所論のように被告人につき本件強盗の間接正犯が成立するものとは、認められない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、被利用者に是非弁別能力があり、被利用者自身の意思で強盗を決意したのであって、指示の態様が「実質的に支配している」とまではいえないといふことを挙げている。したがって、甲には、強盗罪の間接正犯は成立しない。

2 成立する

大判大10.5.7。判例は、本記述と同様の事案において、同意堕胎罪の間接正犯が成立するとしている。その理由として、判例は、堕胎受託者は犯罪行為たる自己の堕胎手段により緊急避難（37条）の状態を発生させ、その発生を機として医師に胎児の排出を求めたのであって、その行為と胎児の排出との間に因果関係があり、医師の正当業務行為を利用して堕胎を遂行した者と評価できるといふことを挙げている。したがって、甲には同意堕胎罪の間接正犯が成立する。

3 成立しない

最判昭27.12.25。判例は、私人が虚偽の事実を記載した証明願を事情を知らない村役場係員に提出して、村長名義の虚偽の証明書を作成させたという事案において、公務員でない者が虚偽公文書作成の間接正犯であるときは、157条のほかにはこれを処罰しないとしている。その理由として、判例は、「156条の他に特に公務員に対し虚偽の申立を為し、権利義務に関する公正証書の原本又は免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をなしたときに限り同法157条の処罰規定を設け、しかも右156条の場合の刑よりも著しく軽く罰しているに過ぎない点から見ると、公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法157条の場合の外これを処罰しない趣旨と解するのを相当とする」ということを挙げている。本記述では、公務員でない甲が公務員である乙をして、公正証書の原本に虚偽の記載をさせているので、公正証書原本不実記載罪（157条1項）が成立する。したがって、甲には、虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しない。

4 成立する

本記述では、間接正犯の形態で私文書偽造罪（159条1項）を犯すことができるかが問題となる。偽造とは、権限なく他人名義の文書を作成することをいう。そして、私文書偽造罪は、作成名義人など作成権限者を欺く等して、間接正犯の形態で犯すことができるとされている。本記述においては、甲は事情を知らない乙を利用して、丙に無断で丙名義の事実証明に関する広告文を作成させている。したがって、甲には私文書偽造罪の間接正犯が成立する。

5 成立する

最決昭31.7.3。本記述では、事情を知らない買主を利用した場合に、売主が窃盗罪（235条）の間接正犯となるかが問題となる。判例は、採炭運搬のために据えつけた他人所有・管理のドラグライン1基を、自己に処分権があるかのように装って売却し、情を知らない買主が、それを古鉄回収業者に搬出させたという事案において、売主は「窃盗罪の刑事責任を免れることはできない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、行為者が、構成要件結果について故意のない媒介者の行為を介入させた場合には、媒介者を道具のように利用して構成要件を実現したとみることができるということを挙げている。したがって、甲には窃盗罪の間接正犯が成立する。